

NORIDAH BINTI MOHAMED NOOR & MOHD HATTA BIN MAHAMUD

Iwn

NURUL IZMA SHAMIRA BINTI OTHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel)]

Pada : 13hb Julai 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0032-2018

Peguam Pemohon: Puan Yusmawati Binti Ab. Llah dari Tetuan Zaidi Yusma & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon-Pemohon Noridah Binti Mohamed Noor dan Mohammad Hatta Bin Mahamud telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10200-083-0043-2018 yang bertarikh 21hb Februari 2018.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

[2] Pemohon-Pemohon adalah Defendan 2 dan Defendan 3 dalam kes kausa tindakan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Mal No.: 10200-083-0043-2018 (Tuntutan Hak Jagaan Anak).

[3] Plaintiff dalam kes tersebut Nurulizma Shamira Binti Othman 16hb Januari 2018 telah memfailkan tuntutan hak jagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam melalui Saman No.: 10200-083-0043-2018.

[4] Tuntutan untuk Mendapatkan Hak Jagaan Anak Plaintiff antara lainnya menuntut;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor mengishtiharkan bahawa anak bernama Muhammad Iman Rayyan Bin Abdullah (No. Sijil Kelahiran: DH 89917) adalah anak tak sah taraf; dan
- b) Suatu perintah bahawa hak jagaan kekal anak bernama Muhammad Iman Rayyan Bin Abdullah (No. Sijil Kelahiran: DH 89917) diserahkan kepada Plaintiff sebagai ibu kandung kepada anak tersebut.

[5] Saman telah diserahkan kepada Defendan 2 dan Defendan 3 pada 28hb Januari 2018. Tiada sebarang pembelaan dan tuntutan balas telah difailkan oleh Pemohon/Defendan sepanjang prosiding berjalan.

[6] Pada 21hb Februari 2018 dengan kehadiran Plaintiff, Peguam Syariyenya, Peguam Defendan 2 dan Defendan 3; dan tanpa kehadiran Defendan 2 dan Defendan 3, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah mendengar pernyataan Plaintiff dan Peguam Plaintiff.

[7] Setelah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah mendengar pernyataan Plaintiff dan Peguam Plaintiff, Mahkamah telah memberikan keputusan seperti berikut;

- i) Mahkamah meluluskan permohonan hak Penjagaan Anak Tak Sahtaraf oleh Plaintiff berdasarkan Seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii) Mahkamah memerintahkan dan mengisytiharkan bahawa anak tersebut yang bernama Muhammad Iman Rayyan Bin Abdullah (No. Sijil Kelahiran: DH 89917) adalah anak tak sah taraf;
- iii) Mahkamah memerintahkan hak jagaan kekal anak tersebut yang bernama Muhammad Iman Rayyan Bin Abdullah (No. Sijil Kelahiran: DH 89917) diberikan dan diserahkan kepada Plaintiff sebagai ibu kandung kepada anak tersebut;
- iv) Mahkamah memerintahkan pihak-pihak berkuasa seperti Jabatan Imigresen Malaysia dan/atau Polis Diraja Malaysia dan/atau Penguatkuasa Agama Islam Negeri Selangor, Penguatkuasa Agama Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Penguatkuasa Agama Islam di Johor Darul Takzim yang berkenaan diperintahkan menggunakan kuasa yang diperintahkan di sini membantu dan/atau mengiringi dan/atau memberikan sepenuhnya kepada Plaintiff dan/atau Peguam Syarie Plaintiff bagi memastikan penguatkuasaan dan pelaksanaan Perintah ini dilaksanakan dengan sempurna dan sepenuhnya; dan
- v) Mahkamah memerintahkan Perintah Interim bertarikh 15.01.2018 tersebut dibatalkan.

[8] Sepanjang prosiding juga tiada sebarang keterangan Defendan-Defendan serta saksi-saksi Defendan didengar oleh Hakim Bicara. Keputusan diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tanpa mendengar keterangan dari pihak Defendan-Defendan.

[9] Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor antaranya adalah seperti berikut;

- a) Anak tersebut yang bernama Muhammad Iman Rayyan Bin Abdullah (No. Sijil Kelahiran: DH 89917) adalah anak tak sah taraf;
- b) Plaintiff iaitu Nurulizma Shamira binti Othman adalah ibu kandung kepada anak tersebut dan dengan itu hak jagaan anak tersebut adalah secara automatic kepada Plaintiff berdasarkan seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
- c) Defendan 2 dan Defendan 3 tiada locus standi dalam tuntutan hak jagaan terhadap anak tersebut berpandukan kes *Ervin Ahbabovic lwn Amalya Evelyn Bte Abdullah*:

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[10] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Saman No.: 10200-083-0043-2018 seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada perenggan 17 Afidavit Pemohon.

[11] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

"Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[12] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: "apa-apa perkara" dan keduanya "prosiding". Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa "apa-apa perkara" tidak begitu jelas maksudnya yang memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan "Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan".

[13] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah

pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah***, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 7hb Mac 2012 sebagaimana berikut:-

"Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa."

[14] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no. 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[15] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan *apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan* seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-

apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[16] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Saman Mal No: 10200-083-0043-2018, Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut mempunyai asas berdasarkan prinsip semakan iaitu berkaitan proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan.

[17] Dalam prosiding kes Saman Mal No: 10200-083-0043-2018, kami mendapati bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memberikan keputusannya tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak Defendan. Kegagalan Hakim Bicara mendengar keterangan Defendan-Defendan adalah bertentangan atau bersalahan dengan Seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[18] Mengikut kaedah asal perbicaraan dalam Islam, setiap penghakiman hendaklah dibuat dengan kehadiran kedua-dua belah pihak iaitu pihak yang mendakwa dan pihak yang kena dakwa. Ini bertepatan dengan sebuah hadis Nabi S.A.W, yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib di mana Rasulullah S.A.W telah bersabda kepadanya yang bermaksud;

"Jika datang dua orang yang berbalah meminta penghakiman kepada kamu, maka janganlah kamu menjatuhkan hukuman kepada pihak yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan pihak yang kedua, setelah itu kamu akan mengetahui bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman."

(Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala' Muhammad bin 'Abd al-Rahman (1963), *Tuhfah al-Ahwazi*, "Bab Ma Ja'a fi al-Qadi La Yaqdi Bayna al-Khasmayn Hatta Yasma'a Kalamahuma", no. hadis 1348, j. 4. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, h. 561)

[19] Hadith di atas menunjukkan bahawa seseorang hakim apabila hendak menjatuhkan hukuman, perlu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan daripada kedua-dua pihak yang berselisih pendapat sebelum dia boleh menjatuhkan sesuatu hukuman. Kejahilan tentang perkara tersebut akan menyebabkan penghakiman itu menjadi tidak tepat dan tidak sah berdasarkan larangan daripada Nabi S.A.W di atas. Hakim juga tidak dapat membuat keputusan yang tepat kerana hakim tidak dapat mengetahui sama ada orang yang kena dakwa mengaku atau mengingkari dakwaan yang dibuat terhadapnya. Selain itu, keterangan atau saksi yang dikemukakan oleh orang yang mendakwa sahaja tidak akan menjadi hujah melainkan setelah orang yang kena dakwa tidak mampu menolak keterangan dari saksi pihak yang mendakwa. Ketika ini, ketidakmampuan orang yang kena dakwa tidak dapat dipastikan disebabkan ketidakhadirannya di hadapan hakim.

[20] Namun demikian, kaedah asal bagi masalah ini (hendaklah mendengar keterangan kedua-dua belah pihak) telah dikecualikan berdasarkan Istihsan. Ini disebabkan telah datang sebuah hadis yang lain mengecualikan masalah ini. Hadis tersebut ialah hadis yang diriwayatkan daripada A'isyah yang bermaksud;

"Bahawa Hindun bin 'Atabah berkata: Ya Rasullah, sesungguhnya Abu Sufyan ialah seorang lelaki yang kedekut. Dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku melainkan sekiranya aku mengambil sesuatu daripadanya sedangkan dia tidak mengetahui. Lalu sabda Nabi S.A.W kepadanya yang bermaksud, "Ambillah nafkah yang mencukupi

bagimu dan anakmu secara yang baik (mengikut adat dan kebiasaan)."

[Ibn Hajar, Ahmad bin 'Ali al-'Asqalani (2006), Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari, "Bab Iza Lam Yunfiq al-Rajul, Falilmar'ah An Ta'khudha Bighayri 'Ilmihi...", no. hadis 5364, j.2. Beirut: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, h. 2399]

[21] Dalam hadis di atas, Rasulullah S.A.W telah menjatuhkan hukuman dengan berpandukan keterangan daripada Hindun sahaja tanpa kehadiran suaminya. Ini menunjukkan keharusan untuk seorang hakim menjatuhkan hukuman sekalipun orang yang kena dakwa tidak hadir dalam perbicaraan tersebut. Hadis ini dikuatkan lagi oleh perbuatan 'Umar dan 'Uthman yang pernah menjatuhkan hukuman tanpa kehadiran orang yang kena dakwa dan tidak ada sahabat-sahabat lain yang mengingkari perbuatan tersebut.

[22] Masalah itu juga diqiyyaskan dengan beberapa permasalahan yang telah disepakati oleh ulama' tentang keharusannya iaitu hukum menjatuhkan hukuman terhadap kanak-kanak yang belum baligh, hukum menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah mati dan hukum menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah didakwa di mahkamah, kemudian dia telah lari sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Dalam semua permasalahan ini, para ulama' telah bersepakat berhubung keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam semua situasi di atas. Selain itu, sekiranya hakim dilarang daripada menjatuhkan hukuman ketika mana orang yang kena dakwa tidak hadir, sedangkan orang yang mendakwa telah mengemukakan bukti yang kukuh bagi menyokong dakwaannya, ini boleh dianggap sebagai satu pengabaian dan penafian terhadap hak orang yang mendakwa. Ia juga

bertentangan dengan tanggungjawab seorang hakim untuk memberi dan menjaga hak setiap individu dalam setiap penghakimannya. [*Al-Khatib, Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syirbini (1997), Mughni al-Muhtaj, j. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 542*]

[23] Oleh yang demikian, Kami berpendapat perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Saman Mal No: 10200-083-0043-2018 bertarikh 21hb Februari 2018 adalah tidak selaras dan tidak bertepatan dengan kehendak Undang-undang dan hukum syarak tanpa ada sebab yang membolehkannya dan ianya telah menyebabkan ketidak adilan kepada Pemohon.

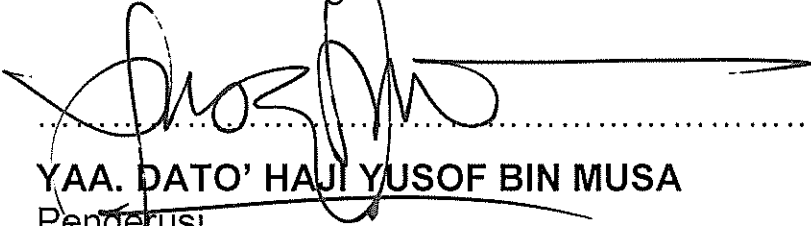
[24] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas kami ~~kami~~, berpendapat bahawa telah berlaku kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut dimana ia telah menjejaskan keadilan; atau/dan proses itu jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Affidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 18hb Mac 2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Permohonan Semakan Pemohon diterima;
- ii] Perintah kes Saman Mal No: 10200-083-0043-2018 bertarikh 21hb Februari 2018 dibatalkan; dan
- iii] Kes Saman Mal No: 10200-083-0043-2018 diperintahkan dibicarakan semula.

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :

10